



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000888432

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001867-33.2016.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante JOAO CARLOS GIMENES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. Face ao novo entendimento exarado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 126.292/SP, recentemente confirmado, vencido o prazo para embargos de declaração, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.

São Paulo, 8 de novembro de 2017.

Guilherme G. Strenger
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO nº 0001867-33.2016.8.26.0595 **VOTO Nº 37014**
Comarca: Serra Negra (Controle nº 1375/2016)
Juízo de Origem: 2ª Vara Judicial
Magistrado Sentenciante: Carlos Eduardo Silos de Araujo
Órgão Julgador: 11ª Câmara
Apelante: JOÃO CARLOS GIMENES
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA

VISTOS.

JOÃO CARLOS GIMENES, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três meses de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, apela (fls. 141 e 172/176), postulando absolvição, sob alegada insuficiência probatória, notadamente pela ausência de exame de corpo de delito direto, ou pelo reconhecimento da excludente de antijuridicidade da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada para a infração penal de vias de fato e a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direito.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contra-arrazoado o apelo (fls. 220/223), em seu parecer a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 238/243).

É o relatório.

Inferre-se do quadro probatório que, no dia 1º de outubro de 2016, por volta das 13h15min, na Rua José Oscar B. da Silveira, nº 605, apartamento 02, Sol Nascente, cidade e Comarca de Serra Negra, o apelante ofendeu a integridade física de Elza Sebastiana Aparecida Nogueira, sua companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, consistentes em escoriação em mão direita e coxa direita.

A condenação do acusado era de rigor e deve prevalecer.

Bem provadas autoria e materialidade delitiva (fls. 04/06, 07/08, 10/11, 15/16, 25/26, 148/149 e 150/151).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em ambas as etapas da persecução penal (fls. 19 e 156/160), o réu refutou a prática da conduta criminosa. Confirmou que, no dia dos fatos, discutiu com a ofendida, mas negou a ocorrência de agressão. Disse que costumava ser agredido pela ofendida. Afirmou que não consegue dobrar uma das pernas e que há uma diferença de três centímetros entre uma e outra, razão pela qual é incapaz de chutar alguém.

Perante a autoridade policial (fls. 07/08), a vítima Elza Sebastiana Aparecida Rodrigues disse que, no dia dos fatos, durante uma discussão, motivada por ciúmes, *“ele me puxou pelos cabelos, pegou o meu celular da minha mão e me deu chutes na minha perna, e então eu fui para a cozinha e de lá ele abriu um armário e pegou uma faca, e passou a faca na minha mão, dizendo que eu não iria sair de casa, eu aproveitei um momento de distração dele e peguei a chave da porta, onde sai correndo na rua e fui para a casa do meu filho, onde*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pedi para ele ligar para a polícia” (fls. 07). Em Juízo (fls. 152/155), alterou parcialmente sua narrativa. Afirmou que “Aquele dia foi assim, eu estava trabalhando nas Vertentes e ele não queria que eu trabalhasse na casa de um homem que eu trabalho até hoje e daí eu menti para ele que eu trabalhava em outra casa e naquele mesmo dia o celular tocou. Daí a gente estava fazendo almoço e o celular tocou e ele correu pegar o celular para ver a ligação e daí ele viu o nome do meu patrão e ele falou 'você está trabalhando lá?' e eu falei 'eu estou' e ele falou 'você mentiu para mim?' e eu falei 'menti porque se eu falasse a verdade você não deixava eu trabalhar lá', ele começou a xingar eu e eu a xingar ele, aí eu fazia comida e no eu puxar ele eu estava com a faquinha na mão e pegou em mim, provavelmente não foi ele que tacou não” (fls. 152/153). Indagada sobre os puxões de cabelo relatados na fase extrajudicial, confirmou. Reafirmou que o réu não a agrediu com uma faca, esclareceu que cortava cebolas e “Eu



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

segurei porque ele veio para pegar a minha faca e eu falei 'não, eu estou cozinhando com ela', daí a faca derrapou e pegou na minha mão, só isso” (fls. 153). Asseverou que foi seu filho quem mandou que dissesse na delegacia que o acusado a chutou, pois queria que ele ficasse preso. Questionada se o réu deu ou não chutes, respondeu: *“Deu um pouco”* (fls. 154). Alegou que esse foi o único dia em que brigaram.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência (fls. 148/149 e 150/151) narraram, *in verbis*: *“No dia dos fatos (...) fomos acionados para atender uma ocorrência num prédio com várias quitinetes, fomos até o local, chegando lá quem atendeu foi a vítima, dizendo que ela havia tido uma discussão com o João e nessa discussão ele havia agredido ela com o pontapé na perna e essa faca que segundo ela era uma faca de serra, eu até subi no apartamento e ela mostrou a faca jogada, mas segundo ela na hora da discussão ela segurou a faca e ele*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

puxou a faca e acabou ferindo ela” (fls. 150). Acrescentaram que “Ela disse que na hora do empurra-empurra ele grudou ela pelos cabelos” (fls. 151).

Mister esclarecer-se, nesse passo, que o miliciano não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

No mais, o laudo de exame indireto de corpo de delito (fls. 25/26), atestou que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em escoriação em mão direita e coxa direita.

A esta altura, insta frisar que, em crimes como no caso em tela, praticados mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, são admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde (fls. 15/16), consoante o disposto no artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06, sendo prescindível a confecção de laudo de exame de corpo de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

delito por peritos oficiais.

Nesse sentido, recente
julgado do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

*“PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA. MEDIDA DE
INTERNAÇÃO. APELAÇÃO
CRIMINAL JULGADA. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE.
VIA INADEQUADA. INFRAÇÃO
NÃO TRANSEUNTE.
VESTÍGIOS. EXAME
PERICIAL. NÃO
DETERMINADO.
MATERIALIDADE DELITIVA.
COMPROVAÇÃO POR
DOCUMENTO E
TESTEMUNHOS. LAUDO
ELABORADO POR MÉDICO*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS. FLAGRANTE
ILEGALIDADE.*

*INEXISTÊNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.*

*[...] 2. Embora tratar-se de
infração não transeunte, não
se fez exame de corpo de
delito por peritos oficiais na
época do crime, conquanto
houvessem vestígios,
inexistindo qualquer menção
acerca da não realização da
perícia no momento próprio.*

*3. Na espécie, inexiste
flagrante ilegalidade, pois a
materialidade delitiva foi
comprovada ao ser a vítima
submetida a exame direto,
logo após o delito, primando
o médico, servidor municipal
de saúde, por elaborar um*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sucinto laudo, pautando-se o magistrado sentenciante não somente em depoimentos testemunhais, mas também em conteúdo probatório outro, qual seja, documento subscrito por profissional de saúde, nos termos do artigo 12, § 3.º, da Lei n.º 11.340/06. 4. Ademais, sob o manto do brocardo da instrumentalidade das formas, inviável o reconhecimento da alegada nulidade, diante do cumprimento da meta circunscrita a comprovação da materialidade do delito. 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ — HC 265208, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

04.11.2014, DJe 14.11.2014).

Dessarte, não trouxe o acusado qualquer prova que pudesse ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os argumentos oferecidos pela defensoria.

A r. sentença bem analisou o quadro probatório dos autos, dando aos fatos perfeita adequação jurídica.

Na reiteração da instância nada de novo foi alegado que infirmasse as conclusões da decisão recorrida.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção de modo a não restar dúvidas da prática do delito em questão pelo acusado, não havendo falar-se em insuficiência probatória.

A esta altura, imperioso salientar que incorre a excludente de ilicitude da legítima defesa, cujos pressupostos (agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

repelida mediante uso moderado dos meios necessários) não se viram comprovados na instrução contraditória.

Igualmente descabido o requerimento de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, pois houve ofensa à integridade física da ofendida, caracterizadora do delito de lesão corporal.

Nesse sentido:

“A distinção entre vias de fato e lesões corporais está precisamente no resultado objetivo: ambas têm como elemento comum a agressão, aliada ao animus laedendi. Mas, se resulta ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, o que se verifica é o crime; quando não, a contravenção. A intensidade da lesão não importa. Por menor que seja, desde que produza um dano anatômico ou perturbações



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

funcionais de certa monta, identifica-se o elemento material da infração” (TJSP, AC. Rel. MENDES PEREIRA, RT 508/347 e RJTJSP 49/337)

“Vias de fato e lesão corporal — Distinção — Quem pratica vias de fato assume necessariamente o risco de provocar ferimentos na vítima, agindo, pois, com dolo eventual de dano a integridade física daquela, residindo a distinção entre esta contravenção e o crime do art. 129 do CP unicamente no resultado objetivo, tendo ambas em comum a agressão aliada ao animus laedendi, tornando-se crime de lesão corporal as vias de fato que provocam ferimentos”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(TACRIM-SP, AC, Rel. DIRCEU
CINTRA, Rolo-flash 1.013/489,
j. 01.02.96)

Ademais, imperioso ressaltar que o fato do casal ter se reconciliado não descaracteriza o crime.

No tocante às reprimendas e ao regime prisional impostos, verifica-se que foram criteriosamente dosados, observadas as especificidades do caso concreto (notadamente a reincidência específica do agente — fls. 93) e de acordo com o livre e prudente convencimento do MM. Juízo de Primeiro Grau.

Neste passo, imperioso anotar ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista tratar-se de crime cometido com violência contra a pessoa e em razão da comprovada reincidência específica do agente (fls. 93), em consonância com o disposto no artigo 44, incisos I e II e § 3º, do Código Penal.

Nada há, portanto, a ser



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

reparado.

Por derradeiro, cumpre salientar que, na esteira do entendimento firmado pelo Plenário do Pretório Excelso por ocasião do julgamento do *Habeas Corpus* nº 126.292/SP (da Relatoria do e. Min. TEORI ZAVASCKI) – no sentido de que a execução provisória de sanção prisional imposta ou confirmada em sede recursal ordinária não vulnera o núcleo essencial do princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade (insculpido no artigo 5º, *caput*, inciso LVII, da Lei Maior) –, faz-se mister, uma vez ratificada a condenação criminal que ora se busca desconstituir, determinar-se, após vencido o prazo para embargos de declaração, a imediata expedição de mandado de prisão contra o apelante.

Diante do exposto, *nega-se provimento* ao apelo. Face ao novo entendimento exarado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Habeas Corpus nº 126.292/SP, recentemente confirmado, vencido o prazo para embargos de declaração, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu.

GUILHERME G. STRENGER
Relator